Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

SENTENÇA

Vistos e examinados estes autos sob nº 0803172-14.2023.8.12.0029 de **AÇÃO Procedimento Comum Cível** em que é **Autor:** Maria Gentiluce da Silva e **Réu:** Estado de Mato Grosso do Sul e outro

Maria Gentiluce da Silva, qualificada nos autos, move a presente **Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada** em desfavor do **Município de Naviraí** e do **Estado de Mato Grosso do Sul,** ambos igualmente identificados no feito, dizendo, em resumo, que é idosa com 88 anos de idade e realiza dieta caseira com sonda por estar impossibilitada de fazer refeições via oral, em consequência de sequelas de doença de Parkinson. Que a dieta caseira não vem surtindo bons resultados, encontrando-se com dificuldades de se alimentar e, por isso, apresenta grande perda de peso, prejudicando seu tratamento de saúde. Que necessita, com urgência, de **suplementação alimentar com dieta hipercalórica e hiperproteica**, durante seis meses, podendo ser Trophic 1,5, Isosource 1,5 ou Fresubin Energy, 30 litros mensais. Conta que tentou obter o suplemento alimentar na via administrativa, porém não obteve êxito e também não tem condições financeiras para adquiri-lo. Com base em tais fatos, objetiva a condenação dos Requeridos ao fornecimento do suplemento alimentar industrializado hipercalórico e hipérproteico na quantidade que lhe foi prescrita. Instruiu a inicial com os documentos de fls. 14/22.

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico às fls. 26/31.

Tutela de urgência deferida (fls. 32/35).

O Requerido Estado de Mato Grosso do Sul na sua resposta postula pelo direcionamento da obrigação ao Município de Naviraí ante o tema 793 do STF (fls. 49/53).

O Requerido Município de Naviraí em sua defesa alegou, em suma, que dieta enteral industrializada só é disponibilizada pelo SUS aos pacientes em regime de internação hospitalar, e não é considerada Medicamento. Postulou pela improcedência do pedido inicial. Juntou documentos (fls. 64/71).

A parte autora apresentou impugnação à contestação, oportunidade em que postulou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 56/57 e 82/83).

Na fase de especificação de provas, apenas o requerido Estado de Mato Grosso do Sul se manifestou, não possuindo provas a produzir (fls. 80).

Manifestação pelo Requerido Município de Naviraí às fls. 90/93.

Ofício referente ao Agravo de Instrumento n.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 25/07/2024 às 14:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803172-14.2023.8.12.0029 e código DL9zBs58.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

1422047-70.2023.8.12.0000 juntado às fls. 95/112.

É o relatório no essencial.

Decido.

Conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do Novo Código de Processo Civil, pois desnecessária a produção de outras provas, o que, aliás, sequer foi requerido por alguma das partes.

O ordenamento jurídico brasileiro tutela o direito à saúde, determinando o artigo 196 da Constituição Federal que:

> "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Por sua vez, a Lei n.º 8.080, de 19/9/90, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estatui em seu artigo 2.º quec *"A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício"*. E, no artigo 7.º, que:

> "As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde − SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: I − universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II − integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; IX − descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;".

Basta o dispositivo previsto no texto constitucional citado para se chegar à conclusão de que se deve garantir o direito de todos, <u>independentemente da condição financeira,</u> à saúde. As normas infraconstitucionais, que procuram dar efeito integrador ao texto constitucional, seriam até despiciendas se existisse a consciência, por parte de todos os responsáveis pelas administrações dos entes federados, de que a Constituição Federal não é puramente analítica. A Constituição, com sua força normativa, constitui energia que deve influir na realidade. O dever da Administração de adquirir o necessário ao atendimento de pessoas doentes, imposto pela Constituição, não pode ser inviabilizado enventualmente através de entraves burocráticos e questiúnculas referentes à competência deste ou daquele órgão para distribuição. A distribuição de competências entre os entes federados é firmada para melhor servir aos cidadãos e não para aumentar seus sofrimentos e angústias, motivo pelo qual há solidariedade entre eles.

A edição da Lei nº 12.401/2011, em que pese sua importância e

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 25/07/2024 às 14:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803172-14.2023.8.12.0029 e código DL9zBs58.

necessidade de respeito, não pode implicar em preterimento dos direitos do cidadão. A lei deve respeito à Constituição Federal e o Poder Judiciário é o garante das promessas do constituinte. Assim, como a Carta Magna traz a promessa de ampla proteção no campo da saúde, não pode o ente público se esquivar da sua obrigação, até porque estamos diante de tema que perpassa pela dignidade da pessoa humana. O Tribunal de Justiça do Estado, a respeito do tema já decidiu:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 12.401/2011 – PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE PREVALECE SOBRE LEI, PORTARIA OU ATO NORMATIVO INFERIOR – DIREITO À SAÚDE – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – MEDICAMENTO EXPERIMENTAL – SEM RELEVÂNCIA DESDE QUE INDICADO POR MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE – RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar no reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n. 12.401/2011, posto que já é pacífico o entendimento de que a garantia ao acesso igualitário das pessoas saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal está acima de qualquer lei, portaria ou ato normativo inferior. Uma vez sopesados os interesses de ambas as partes, verifica-se que o princípio da integralidade que é fundamento do interesse do recorrente, não deve prevalecer sobre o princípio basilar da pretensão do recorrido, que é o da dignidade da pessoa humana. Diante da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, como a prova inequívoca do direito e a verossimilhança das alegações acerca da necessidade do medicamento pleiteado, a decisão a quo deve ser mantida. Já é sedimentado o entendimento de que, se beneficiar o paciente, o médico pode utilizar um medicamento para finalidades diversas das indicadas, mesmo que em fase experimental. (TJMS, Quarta Câmara Cível, relator Desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte, agravo nº 2012.015841-8, julgado em 17.07.2012).

Desse modo, é patente a responsabilidade dos réus quanto ao atendimento das demandas relacionadas à saúde, o que, de resto, ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 793, que estabeleceu a seguinte tese:

> Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, **compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento** conforme as regras de repartição de competências **e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro**. (Grifei)

Portanto, os Requeridos não podem se esquivar do cumprimento da obrigação, embora caiba ao juiz estabelecer, caso a caso, qual ente federativo deverá cumpri-la com prioridade.

Demonstrada a responsabilidade dos Requeridos, verifico que,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 25/07/2024 às 14:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803172-14.2023.8.12.0029 e código DL9zBs58.

no caso, a parte autora demonstrou que possui uma demanda na área da saúde e que não conseguiu dos demandados, administrativamente, o atendimento de que necessita.

Os documentos de fls. 17/18 demonstram que a parte autora necessita de alimentação industrializada para tratar adequadamente seu problema de saúde, o que não pode ser negado pelos réus.

Nesse sentido, reitero a decisão que deferiu a tutela de urgência (fls. 32/35), cujos fundamentos permanecem inalterados. Nesse sentido, para melhor compreensão da questão, cito, em destaque, os seguintes trechos da decisão:

> "O laudo médico de f. 17 e laudo nutricional de f. 18 comprovam a necessidade da suplementação alimentar para a recuperação da saúde da idosa, demonstrando a ineficácia da dieta caseira:

AO NUTRICIONISTA,

SOLICITO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DOMICILIAR PARA A PACIENTE MARIA GENTILUCE DA SILVA, 88 ANOS. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE PARKINSON, EPILEPSIA, RESTRITA AO LEITO POR SINDROME DE IMOBILIDADE POR SEQUELAS DE AVC, E FAZ USO DE TRAQUEOSTOMIA E GASTROSTOMIA.

PRESCREVO DIETA ISENTA DE SACAROSE E LACTOSE, HIPERPROTEICA E HIPERCOLÓRICA.

VOLUME DE 200 ML DE 3/3 HORAS POR DIA, SENDO CINCO REFEIÇÕES / DIA, TOTALIZANDO 1.000 ML / DIA, 31 LITROS / MÊS.

FRASCOS - 30 UNIDADES/ MÊS.
EQUIPOS- 30 UNIDADES / MÊS.

OPÇÕES DE DIETAS:
1- ISOSOURCE 1.5
2- TROPHIC EP
3- TROPHIC 1.5
4- NUTRISON ENERGY 1.5
5- NUTRI FIBER 1.5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 25/07/2024 às 14:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803172-14.2023.8.12.0029 e código DL9zBs58.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

Prescrição Nutricional

Declaro que a Sra. **MARIA GENTILUCE DA SILVA,** 88 anos e 07 meses, sequelas de Doença de Parkinson (CID10 - G20), traqueostomizada e alimentação via gastrostomia, impossibilitada de realizar refeições via oral, vem realizando dieta caseira, desde que a sonda foi iniciada, a dieta caseira não vem apresentando bons resultados, pois houve perca de peso progressiva e o paciente se encontra com diagnóstico de baixo peso, necessitando com **URGÊNCIA** de uma suplementação alimentar com dieta hipercalórica e hiperproteica.

Necessita com **URGÊNCIA** de 30 litros mensais de dieta enteral hipercalórica (Trophic 1,5 ou Isosource 1,5 ou Fresubin Energy) por 06 meses.

No mais, o parecer do NAT foi favorável ao pedido (f. 26-31).

É certa a necessidade da parte autora de receber a alimentação industrializada para que tenha garantida sua saúde.

Nada obstante, a parte autora informou que não tem condição financeira de adquirir a alimentação que necessita, situação presumível no caso, já que se encontra assistida pela Defensoria Pública local e em razão das suas enfermidades, certamente, se recebe algum provento, é consumido por suas demandas de saúde.

Dessa maneira, não possuindo a parte Autora condições de arcar com os custos da alimentação especial, havendo prescrição médica que recomenda a utilização do suplemento alimentar industrial e, ainda, tendo em conta a especial proteção do Estado e da sociedade à pessoa idosa, como bem se vê no art. 230 da Constituição Federal e no art. 3º do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/203), está demonstrada a probabilidade do direito alegado."

E não há falar que o atendimento somente deverá ser fornecido quando houver risco de morte, pois a Constituição garante a saúde em suas mais variadas acepções, inclusive como um processo de "bem-estar" geral ou social. É evidente que todos têm o direito de viver de forma digna e com saúde, o que está intrinsecamente ligado à garantia de recebimento de atendimento adequado pelo serviço universal e integral que deve ser prestado pelo Estado em suas diversas esferas.

Por oportuno, destaca-se que não se trata de judicializar políticas públicas, mas de garantir o atendimento adequado a quem dele necessita. É fazer com que o

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 25/07/2024 às 14:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803172-14.2023.8.12.0029 e código DL9zBs58.

Estado (sentido amplo) cumpra seu papel, cumpra as políticas públicas com as quais deveria estar comprometido, cumpra os fins do Estado estabelecidos na Constituição.

Do dispositivo

Ante o exposto, confirmando neste momento a antecipação dos efeitos da tutela, **JULGO PROCEDENTE** o pedido que **Maria Gentiluce da Silva** fez em desfavor do **Município de Naviraí** e do **Estado de Mato Grosso do Sul**, qualificados, para o fim de determinar aos Requeridos que forneçam, por meio de seu órgão executor competente, à parte Autora, o **suplemento alimentar industrializado hipercalórico e hiperprotéico** que ela necessita, podendo ser Trophic 1,5, Isosource 1,5 ou Fresubin Energy, ou suplementos industrializados equivalentes, independentemente da marca, na quantidade e pelo tempo necessário para seu tratamento, mediante a apresentação de receituário médico ou de nutricionista, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação dos réus do teor desta decisão.

Deixo de fixar multa pelo descumprimento da obrigação, pois, segundo consta dos autos, ela foi cumprida (vide autos n. 0800516-50.2024, fls. 34).

Por oportuno, DIRECIONO o cumprimento da obrigação supra ao Município de Naviraí, pois segundo o NAT (f. 29, item VIII), o referido ente público é o responsável pelo atendimento, o que faço em vista das premissas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. No caso de custeio desta obrigação pelo Estado de Mato Groso do Sul, que seja garantido o direito ao ressarcimento, administrativamente ou em ação própria. No entanto, resta mantida a solidariedade entre os entes públicos demandados quanto ao cumprimento da obrigação frente à parte autora.

Sem custas, *ex vi legis*.

Em vista do que restou decidido no Tema n. 1.002 do STF[1], condeno os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que fixo em R$800,00 (oitocentos reais), com fulcro no art. 85, §8º do Código de Processo Civil, já considerado o grau de zelo do profissional, a importância e a natureza da causa, o tempo e o lugar da prestação do serviço. Ainda, com fulcro no art. 87, § 1º, do CPC, determino a distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais em 50% entre os litisconsortes passivos, ou seja, cada Requerido deverá arcar com a metade dos honorários fixados.

Declaro **extinto** o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sentença sujeita a reexame, pois não é certo o valor da condenação, nos termos do art. 496, § 3º, do CPC e Súmula 490 do STJ.

[1] O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, fixou tese vinculante no sentido de que "é devido o pagamento de *honorários* sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra."

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 25/07/2024 às 14:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803172-14.2023.8.12.0029 e código DL9zBs58.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

Assim, decorrido o prazo recursal, mesmo sem oposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E. TJMS para reexame.

Havendo o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades.

P.R.I.C.

Naviraí/MS, **datado e assinado digitalmente.**

Eduardo Magrinelli Júnior
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 25/07/2024 às 14:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803172-14.2023.8.12.0029 e código DL9zBs58.